

1503342-33.2020.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... destacar que, para configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.

A propósito anoto:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503342-33.2020.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503342-33.2020.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262996/2020 - DISE-

DEL.SEC.ARARAQUARA, 14286521 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 83/20/128 - DISE-

DEL.SEC.ARARAQUARA, 2262996 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO VENTURA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Vistos.

LEONARDO VENTURA MARTINS, qualificado nos autos, foi processado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 22 de outubro de 2020, por volta

das 16h10min, na Avenida Pedro José Laroca, n. 2865, bloco 15, apartamento n. 14, e nas imediações de estabelecimento de ensino, o acusado trazia consigo e maninha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 06 (seis) porções de maconha, com três cigarros de maconha parcialmente consumidos, além de 06 (seis) porções de cocaína, todas as drogas individualmente embaladas e prontas para a venda, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acompanha a denúncia Auto de Prisão em Flagrante. A prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva, consoante decisão de fls. 59/60.

A denúncia foi recebida no dia 05 de novembro de 2020 (fls. 104/105). Citado (fls. 126), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 189/207). O acusado foi posto em liberdade em cumprimento de ordem do E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 152/160).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado ao final (fls. 162/163).

Nos debates, a acusação pugnou pela procedência da ação, para condenar os acusados nos exatos termos da denúncia, por entender presente a materialidade e autoria.

O Defensor Público, a seu turno, pugnou pela absolvição do acusado ante a insuficiência de provas para o decreto condenatório, destacou, outrossim, que seria o caso de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Assim, postula a improcedência com esteio no artigo 386, inciso VII (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal, ou sua desclassificação para o delito acima mencionado. Para eventual condenação nos termos da denúncia, postula a reprimenda menos gravosa, regime aberto, tráfico privilegiado, substituição por penas restritivas e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para o julgamento.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência de fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, do laudo de constatação prévia de fls. 14/21, do laudo químico toxicológico definitivo de fls. 71/75 e laudo do local demonstrando que se encontra nas proximidades de entidade de ensino (fls. 100/103).

A autoria também é incontestada.

Leonardo Ventura Martins, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito, disse que seria apenas usuário de entorpecentes. Afirmou que a droga apreendida não era sua, porque seria apenas um usuário (mídia).

Em que pese a negativa do acusado, sua versão restou isolada nos autos frente a todo conteúdo probatório. Vejamos.

Fábio Augusto Campos e José Luís Neiva, policiais militares, testemunhas devidamente compromissadas e sob o crivo do contraditório, em seus depoimentos judiciais narram que no dia dos fatos estavam participando de operação na área comum e externa ao conjunto de prédios populares do Jardim Oitis, pois é um local de alto e permanente tráfico, tanto em apartamentos, quanto na área comum, praticado por vários indivíduos e, uma vez no local, notaram o acusado que, ao perceber a presença dos policiais e sem motivo, saiu correndo, por isso foi detido e abordado. Frisaram que em frente à porta de seu apartamento, encontraram na busca

inicial a quantia de R\$ 20,00 em sua posse, depois lograram êxito em localizar as porções das drogas descritas na denúncia próximo aos pés do acusado. Disseram que o acusado negou a propriedade das drogas e não assumiu ser usuário. Ressaltaram, por fim, que o local fica próximo de uma entidade escolar (gravação audiovisual de fls. 309).

Entendo que, o depoimento policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal.

Nesse sentido anoto:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266)

"Prova - Testemunhas - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante." (RT 771/566)

É oportuno destacar que, para configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.

A propósito anoto:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização." (RT 714/357)

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido." (RT 729/542)

Assim, a prisão do acusado seguida do encontro das drogas, bem como a quantidade, variedade e a forma de acondicionamento, corroboram os depoimento judiciais dos policiais, pois denotam que os entorpecentes apreendidos efetivamente se destinavam ao comércio ilícito.

Registre-se que a eventual condição de usuário de drogas não excluiria sua responsabilidade criminal pela prática do tráfico de drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício.

Por fim, há ainda que se considerar a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porquanto restou caracterizado o tráfico foi praticado perto de entidade de ensino, conforme se observa nestes autos.

Assim, o conjunto probatório, portanto, é robusto quando à materialidade e autoria do delito, assim como a destinação da droga à mercancia ilícita, já que a

quantidade da droga apreendida é manifestamente incompatível com o que normalmente portam meros usuários.

De rigor, portanto, a condenação do acusado no crime tráfico, pelo que, atento ao sistema trifásico (art. 68, CP), passo a dosar-lhes as penas, nos termos do artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando a primariedade e bons antecedentes do acusado, conforme certidões de fls. 39/40, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas. E, muito embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal não deve incidir. Não entendo ser o caso de aplicação por caráter objetivo, deve influenciar ou facilitar a prática do crime.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial." (AgRg no H655.339/SP T5 - Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J. em 13.4.2021 DJe em 19.4.2021).

No mesmo sentido o C. Tribunal de Justiça, veja-se:

"Na segunda fase do cálculo, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II alínea "j", do Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "53. Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgrças particulares de alguém. Ex: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro." (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401). No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime. A conduta do réu, que já não se encontrava em isolamento social, por ser morador de rua, de subtrair os objetos do interior de um carro estacionado em via pública não se amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma desgraça particular ou coletiva, como incêndio, enchentes, acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes contra vítimas que se encontram em posição de maior vulnerabilidade decorrente

dessas situações'." (Ap. 1510214-73.2020.8.26.0228 - Rel. Xavier de Souza - j. 14.9.2020).

Por fim, na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, razão pela qual elevo a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583. Ausentes causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Em arremate da reprimenda, importa dizer que não se cogita do redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a causa de redução é dirigida ao chamado "pequeno traficante", mas a quantidade de droga apreendida e variedade, bem como a complexidade dos fatos e a gravidade do crime, indicam que o acusado não se ajusta a esse conceito. Aliás, nesse exato sentido manifestou-se na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, o Deputado Paulo Pimenta, relator para o PLS nº 115/2002, da Lei nº 11.343/2006, em parecer de 10 de fevereiro de 2004: "Não olvidamos da diferença existente entre pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma causa especial de diminuição da pena para o agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja conduta se caracterize por ausência de habitualidade e caráter não profissional".

Quanto ao regime do cumprimento da pena privativa, nos termos do artigo 33, do Código de Processo Penal, anoto que a infração em tela é equiparada aos delitos hediondos (Lei 8.072/90), e independentemente da quantidade de pena, impõe a fixação do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07), mais favorável aos acusados, já que a redação anterior se referia ao regime integral fechado. Além disso, o regime inicial fechado é o único compatível para repressão do delito aqui tratado, e prevenção da prática de outros dessa natureza.

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a teor da atual situação financeira do réu.

Por fim, destaco que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, seguindo a vedação do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06. E nem se diga que o julgamento do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade em controle difuso teria reflexo ao caso em tela. Primeiro porque não possui força vinculante, segundo porque o caso concreto deve se adequar a tal hipótese no sentido de considerar como medida razoável, algo que não se vê dos autos, já que estamos diante de um crime equiparado aos delitos hediondos, com graves e nefastos efeitos em nossa sociedade, principalmente nesta pequena cidade do interior paulista.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e condeno o réu LEONARDO VENTURA MARTINS à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Decreto a perda do dinheiro a teor do artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 1º e seguintes da Lei n.º 1.060/50.

P.I.C.

Araraquara, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA